



Tribunale di Roma

Prima SEZIONE LAVORO

N. R.G. 6844/2025

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica della persona del giudice dott.ssa Maria Casola, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 marzo 2025, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 198/2006

nella causa promossa da:

Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Milardi

CONTRO

CP_1 on sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Indaco e dall'Avv. Michelangelo Capua

Con ricorso ex art. 38 D.lgs. 198/2006, depositato in data 25.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la *CP_1* chiedendo:

- “1) Accertare, dichiarare e statuire la sussistenza di un comportamento discriminatorio posto in essere dalla società resistente ai danni e nei confronti della Dott.ssa *Pt_1* in ragione del suo stato di madre e consistita nel mancato rinnovo del contratto a termine;
- 2) Per l'effetto, rimuovere gli effetti di tale discriminazione, ordinando e/o disponendo la proroga del contratto a termine della ricorrente dalla data della scadenza e fino alla cessazione della convenzione con il *CP_2* ;
- 3) Per l'ulteriore effetto, condannare la società resistente, per i motivi di cui in narrativa, alla tutela risarcitoria ex 38 del D. Lgs. n. 198/2006 in favore della ricorrente nella

misura pari alle retribuzioni non godute dalla data della scadenza del contratto fino alla stipula della proroga del contratto a termine;

4) Accertare e dichiarare l'esistenza di un danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno alla salute ed all'integrità psico/fisica quale conseguenza della discriminatoria, illegittima ed infondata mancata proroga del contratto a termine;

5) Per l'effetto, condannare la società resistente a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale nella misura che sarà determinata in corso di causa, ovvero in quella somma diversa che sarà ritenuta equa e di giustizia anche in tal caso invocando il potere equitativo del Giudicante ex art. 1126 c.c. e 432 c.p.c., in conseguenza della violazione dei principi costituzionali sopra riportati e della dedotta discriminazione;

6) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”.

In via subordinata, la ricorrente ha avanzato la propria domanda anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

La parte convenuta si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita con prove documentali; quindi è stata discussa oralmente.

A scioglimento della riserva assunta, il giudice osserva quanto segue.

1. *Il rito speciale*

Preliminarmente, deve darsi atto che la parte ricorrente, almeno per la proposizione delle domande avanzate in via principale, ha correttamente proposto l'azione nelle forme previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 196/2006.

Sul punto, è giusto il caso di precisare che questo strumento si caratterizza come procedimento speciale di natura sommaria, che si conclude con l'emissione di un decreto motivato ed immediatamente esecutivo, con cui è possibile ordinare all'autore

del comportamento denunciato la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita.

La disposizione citata (art.38 d.lgs. n.198 del 2006) stabilisce poi, al comma 3, che "Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile".

Per esigenze di completezza, sin da ora, è da chiarire che la disposizione dell'art. 38 impone un nesso di facoltatività ed alternatività di questo procedimento speciale rispetto alle forme processuali ordinarie di esercizio dell'azione giudiziaria. In tal senso, la clausola di riserva che compare in esordio al comma 6 dell'art.38 d.lgs. n.198 del 2006 ("Ferma restando l'azione ordinaria"), opera come disposizione di salvaguardia della possibilità per la parte interessata di promuovere l'azione a tutela dei diritti lesi nelle forme ordinarie ovvero anche nelle forme comuni del procedimento cautelare, ai sensi dell'art.669 bis sgg. c.p.c. o ex art.700 c.p.c.

In conseguenza di ciò, ricordato che nel ricorso risulta inserita, pure se in via graduata, anche una domanda formulata ai sensi dell'art. 700 c.p. la medesima deve ritenersi improponibile, stante il ritenuto ostacolo all'esercizio congiunto dello strumento speciale sommario e di quello cautelare atipico conseguente alla predetta alternatività dei rimedi.

2. *L'oggetto della domanda*

Andando quindi a valutare l'oggetto della domanda attorea, la dott. Pt_1 ha lamentato di essere stata vittima di una condotta discriminatoria posta in essere dalla società resistente, in relazione alla mancata proroga del suo contratto di lavoro a tempo determinato, deducendo che tale scelta sarebbe stata determinata esclusivamente dal suo stato di maternità.

A fondamento della domanda, la ricorrente, oltre ad avere illustrato in dettaglio le vicende relative al proprio rapporto di lavoro con la resistente, ha precisato che, a

differenza di altri due lavoratori, assunti a tempo determinato con la medesima selezione, dei quali uno addetto ad identiche mansioni, solo il suo contratto non è stato prorogato e ciò costituirebbe un indice del trattamento discriminatorio subito.

La società, da parte sua, ha essenzialmente contestato l'esistenza di un qualsiasi nesso di collegamento causale tra la maternità della ricorrente e la scelta datoriale. In particolare, la convenuta, ha precisato di avere adottato una decisione pienamente legittima e conforme al principio di libertà di iniziativa economica garantito dall'art. 41 della Costituzione, essendo la stessa fondata esclusivamente su esigenze organizzative e produttive.

Inoltre, la società ha rilevato che il ricorso introduttivo risulterebbe gravemente carente sotto il profilo probatorio, non avendo la ricorrente assolto l'onere minimo richiesto dall'art. 40 del Codice delle Pari Opportunità per l'inversione dell'onere della prova. Nello specifico, ciò è stato argomentato in quanto il mero confronto con le sorti di soli altri due lavoratori (*Persona_1* , e di *Persona_2*) non risulterebbe statisticamente significativo, né idoneo a far sorgere una presunzione di discriminazione, in assenza di elementi oggettivi e concordanti che dimostrino un trattamento sistematicamente sfavorevole nei confronti delle lavoratrici madri.

3. *Regime giuridico applicabile alla fattispecie sostanziale*

Così determinato e sunteggiato l'oggetto della domanda, è dovere del giudice individuare le fonti regolative della fattispecie, per poi valutare la sussumibilità dei fatti come accertati nell'ambito della previsione normativa astratta.

Il quadro regolativo attinente alla fattispecie per cui è causa è molto articolato ed intrinsecamente complesso, ma si giova di una ricostruzione giurisprudenziale ormai consolidata.

In particolare, riprendendo proprio l'ampia analisi contenuta nella sentenza della Suprema corte n. 5476/2021, bisogna, intanto, dare atto che la discriminazione collegata alla gravidanza e alla maternità costituisce una forma particolare di discriminazione di genere.

Per proteggere in modo specifico le persone esposte a questo particolare fattore di rischio, è venuta sviluppandosi nel tempo, in sede nazionale e sovranazionale, un robusto sistema regolativo.

L'art. 157 del TFUE sancisce l'obbligo della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile e stabilisce un fondamento giuridico generale per l'adozione di misure riguardanti l'uguaglianza di genere, incluse la parità e la lotta alla discriminazione sulla base della gravidanza o della maternità sul luogo di lavoro.

L'art. 33, paragrafo 2, della Carta dell'UE sancisce, poi, che: «Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio».

Vanno poi menzionate le diverse direttive europee che vietano la discriminazione rispetto ai diversi fattori di rischio, già contemplati nell'art. 10 del Trattato.

In particolare, per quanto qui d'interesse, deve essere certamente citata la direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso ai beni e ai servizi (direttiva 2004/113/CE) e la direttiva sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego 2006/54/CE, particolarmente rilevante in quanto ha riunito e modificato le direttive riguardanti l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (cd. di rifusione).

Infine, la direttiva 92/85/CE ha introdotto disposizioni per l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e dalla direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale.

Per completezza, è bene anche dar conto del fatto che la Corte di Giustizia UE è intervenuta più volte sul tema, peraltro precisando (C 177/88, Dekker del 14 novembre 1989 e CGUE, C-179/88, Hoejesteret dell'8 novembre 1990) che, poiché soltanto le donne possono rimanere incinte, il rifiuto di assumere o il licenziamento di una donna incinta per il suo stato di gravidanza o maternità costituiscono una discriminazione diretta ondata sul sesso che non può essere giustificata da alcun interesse, compreso quello economico del datore di lavoro.

Per l'attinenza con la quaestio facti, si ricorda altresì che, in altra occasione, (decisione C-438/99, *Persona_3* del 4 ottobre 2001) la Corte ha dichiarato che «qualora il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato sia motivato dallo stato di gravidanza della lavoratrice, esso costituisce una discriminazione diretta basata sul sesso» incompatibile con il diritto dell'UE. Inoltre, una donna non è tenuta a comunicare la sua gravidanza al datore di lavoro nel processo di assunzione o in qualsiasi altra fase del rapporto di lavoro (CGUE, C-32/93, Webb, 14 luglio 1994; CGUE, C-320/01, Busch, 27 febbraio 2003.).

In ogni caso, la Corte ha ulteriormente ribadito che qualsiasi trattamento sfavorevole direttamente o indirettamente connesso alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso (CGUE, C-32/93, Webb cit.; CGUE, C-421/92, Habermann 7 R. Gen. N. 2636/2015 *Per_4*, 5 maggio 1994; si veda anche CGUE C- 531/2015 *Persona_5* 19 ottobre 2017 secondo cui, punto 55:«in base all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/54, la discriminazione comprende, in particolare, qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva». Il quadro ricostruttivo non può, poi, non tener conto dell'importante contributo offerto in materia dalla *Per_6* che ha dichiarato che l'uguaglianza di genere è uno dei principali obiettivi perseguiti dagli Stati del Consiglio d'Europa (*Per_6* *Persona_7* c. *Per_8* [GC], n. 30078/06, 22 marzo 2012, punto 127).

Quanto all'ordinamento nazionale, deve prima di tutto essere richiamato il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ed il successivo d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

L'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2006, nell'attuale formulazione, prevede che: «Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un

altro lavoratore in situazione analoga».

Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce, poi, che: «Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

Il successivo comma 2-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera p), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2010, stabilisce che: «Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti».

Ora, tanto premesso, rispetto al *thema decidendi* è imprescindibile intanto considerare che costituisce discriminazione diretta qualsiasi atto o anche comportamento che “produca un effetto pregiudizievole” discriminando in ragione del sesso o determinando un “trattamento meno favorevole” rispetto a quello di un'altra persona in situazione analoga. Dunque, la fattispecie legale è imperniata su un dato prettamente oggettivo ed attinente non al piano delle cause o dell'intenzionalità soggettiva delle azioni, ma dei loro effetti.

In ciò si coglie, cioè, la portata puramente oggettiva della discriminazione vietata nei confronti di un soggetto portatore del fattore di rischio, in quanto ritenuta rilevante dalla legge non per l'intenzionalità della condotta o per l'*animus nocendi* datoriale, ma per le conseguenze che di fatto genera.

In ciò, si coglie peraltro la netta distinzione tra la discriminazione ed il motivo illecito determinante.

Inoltre, non può essere trascurato che l'ordinamento vieta anche la discriminazione indiretta, sussistente quando anche solo “un criterio”, formalmente omogeneo e apparentemente neutro è in grado di mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso. In questo caso, facendosi solo eccezione per l'ipotesi in cui il parametro utilizzato attenga a requisiti

essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, e sussista la legittimità dell'obiettivo perseguito e la necessità ed adeguatezza dei mezzi impiegati, lo svantaggio di genere prodotto dal parametro neutro, crea la discriminazione.

Si aggiunga che tale ultima disposizione, in quanto consente di derogare al principio di non discriminazione, va interpretato restrittivamente (v., per quanto riguarda la discriminazione fondata sul sesso, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, *Per_9*, Racc. pag. 1651, punto 36, e 26 ottobre 1999, causa C-273/97, *Per Per* Racc. pag. I-7403, punto 23, nonché, quanto all'art. 2, n. 5, della direttiva 2000/78, in tal senso, sentenza *Per_12*, cit., punto 60).

4. Regime probatorio applicabile

Come più volte richiamato, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006, dispone che, nei giudizi antidiscriminatori, sia proposti con le forme del procedimento speciale sia con quelle dell'azione ordinaria (Cass. 5 giugno 2013, n. 14206 -), i criteri di riparto dell'onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all'art. 2729 cod. civ., bensì quelli speciali ivi previsti.

La norma cioè non crea, a rigore, una deroga all'art. 2697 c.c., cioè un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'agevolazione del regime delle presunzioni semplici in favore del ricorrente.

In conseguenza di ciò e schematicamente, la parte che agisce deve allegare e poi provare: il fattore di rischio (quindi l'appartenenza al genus protetto) ed il trattamento meno favorevole rispetto a posizioni comparabili.

A fronte di ciò il datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della direttiva n. 2006/54/CE - che ha riprodotto il testo dell'art. 4 della direttiva 97/80/CE citata -, deve allegare e provare le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta, in quanto dimostrative dell'assenza della disparità o dimostrative della legittimità di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, nella stessa posizione (v. in tal senso, tra le più recenti, Cass. gennaio 2020, n. 1; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25543).

5.1 fatti di causa

Tanto assodato, dal punto di visto del fatto, il giudice dà atto che le circostanze storiche rilevanti, almeno come ricostruite nella presenta fase, sono tutte pacifiche e comunque dimostrate *per tabulas*.

La ricorrente ha partecipato alla selezione di 3 Esperti Tecnici Informatici, di cui all'avviso pubblico per il Cod. Rif. 2023.14.1, e, dal 5.2.2024, è stata assunta a tempo determinato dalla CP_1 in mansioni riconducibili a quelle del III° livello ccnl Settore Gas-Acqua (All.1-2).

Tale reclutamento è stato posto in essere in ragione della Convenzione Quadro tra la CP_1 ed il Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica del 9 giugno 2020 e ss.mm.ii

La ricorrente dal 9.04.2024 al 03/07/2024, è stata assente dal lavoro a causa di maternità a rischio e, dal 03/07/2024 al 04/12/2024, ha goduto di congedo ordinario di maternità e, dal 05/12/2024 alla scadenza del contratto, di congedo parentale.

In prossimità della scadenza del contratto, appreso che gli altri contratti di lavoro scaturiti dalla medesima selezione erano stati prorogati, la Pt_1 risulta avere richiesto alla propria Responsabile, Parte_2 informazioni, giusta e-mail del 2.12.2024, ricevendo notizia (con email del 3 e 4 dicembre) della nuova collocazione cui sarebbe stata destinata al rientro dalla maternità.

Con comunicazione del 7.1.2025 la D.ssa Parte_3, ha comunicato che la mancata proroga del contratto era dipesa dal venir meno del profilo professionale.

Risulta altresì che, sui tre dipendenti assunti quali Esperti Tecnici Informatici Cod. Rif. 2023.14.1 Persona_1 mico, Persona_2, Persona_13, l'unica a non aver goduto della proroga contrattuale è stata solo la ricorrente.

L'Atto di proroga della Convenzione del 31.10.2024 ha disposto un pieno differimento del termine di durata del contratto, senza alcuna modificazione, con assoluta continuità e costanza delle modalità e delle condizioni negoziali.

5. Valutazione giuridica dei fatti

I dati storici allegati e provati dalla ricorrente dimostrano senza alcun dubbio che la società ha violato la normativa antidiscriminatoria sopra illustrata.

Sul punto, il giudice evidenzia i seguenti punti salienti:

- La dott.ssa **Pt_1** assunta in data 5.2.2024, è stata assente dal lavoro dal 9.4.2024 alla scadenza del contratto (31.12.2024) per ragioni correlate alla gravidanza e maternità;
- Tra i tre dipendenti assunti insieme a lei quali esperti tecnici informatici la ricorrente è l'unica a non avere ottenuto la proroga del contratto;
- La convenzione a monte sopra citata risulta essere stata prorogata alle stesse condizioni e agli stessi patti;
- La società ha dedotto che "il processo produttivo non risultava limitato a causa dell'integrazione di sole due risorse", anziché tre.

Ebbene, nel caso di specie, i dati storici acquisiti, nei limiti della presente fase consentono di affermare che il mancato rinnovo o la mancata proroga del contratto a termine della lavoratrice madre integra una discriminazione basata sul sesso.

Difatti, a parità della situazione lavorativa della medesima rispetto ad altri lavoratori ed a fronte delle esigenze di proroga del servizio, manifestate attraverso il mantenimento in servizio degli altri lavoratori con contratti analoghi alla **Pt_1** risulta essere stato riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza.

In merito, torna utile ricordare che, nella sopra citata sentenza della Corte di Giustizia CE del 4 ottobre 2001 - C-438/99 è stato precisato, punti 45 e 46: «E' altrettanto evidente che il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato, quando questo è arrivato alla sua normale scadenza, non può essere equiparato ad un licenziamento e, di per sé, non è in contrasto con l'art. 10 della direttiva 92/85. Tuttavia [...], in determinate circostanze il mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato può essere considerato alla stregua di un rifiuto di assunzione. Ora, secondo una giurisprudenza costante, un rifiuto d'assunzione per motivo di gravidanza di una lavoratrice pur giudicata idonea a svolgere l'attività di cui trattasi rappresenta una discriminazione diretta basata sul sesso in contrasto con gli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, della direttiva 76/207» (si vedano anche la già citata sentenza 8 novembre 1990, causa C-177/88, Dekker, punto 12 nonché la sentenza 3 febbraio 2000, causa C-207/98, Mahlburg, punti 27-30).

Nella specie, la ricorrente ha fornito elementi di fatto, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di comportamenti discriminatori in ragione del sesso, ma il convenuto non ha adeguatamente assolto all'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

Infatti, fondamentalmente vale considerare che la giustificazione fornita dalla parte convenuta, anche ad ammetterne la verità storica, non è comunque tale da escludere il carattere discriminatorio. Infatti, la giustificazione addotta risiede, da un lato, nell'avvertita sufficienza di due sole risorse, anziché tre, dall'altro, nella preferenza, nella scelta finale selettiva, di coloro che presentavano una maggiore esperienza e capacità.

Ora, però, la materia del contendere non verte sulla scelta datoriale di ridurre il numero complessivo di risorse assegnate al servizio di cui sopra, né sulla non assegnazione ad altri della posizione della *Pt_1* ma verte solo sulla scelta effettuata tra i tre papabili. Analogamente, la *quaestio* non attiene al se la dipendente avesse o meno un diritto contrattualmente riconosciuto alla proroga o al rinnovo, ma alla valutazione del perché, in una cerchia di tre dipendenti equipollenti e comparabili, proprio e solo la lavoratrice madre abbia subito la mancanza di proroga.

In tale direzione, si comprende l'irrelevanza dei capitoli di prova articolati da parte convenuta.

Il tema si pone infatti in termini di comparazione interna tra più posizioni in astratto equipollenti, e ciò secondo un criterio unico, di valenza negativa e positiva, e, comunque lo si valuti, il risultato di apprezzamento finale della fattispecie esprime un contenuto ed un effetto discriminatorio.

Invero, sia considerando in termini negativi, il comportamento datoriale di non prorogare proprio e solo il contratto dell'unica dipendente di sesso femminile ed interessata dall'evento della maternità, esprime un contenuto di oggettiva differenziazione pregiudizievole e di svantaggio, correlabile alla situazione storica oggettiva in cui si è trovata la lavoratrice.

Inoltre, anche considerando in positivo, il criterio discrezionale utilizzato per prorogare il contratto proprio e solo ai due dipendenti di sesso maschile, non implicati in vicende di

paternità (*Persona_1* , *Persona_2*), deve comunque rassegnarsi la conclusione di discriminatorietà indiretta del comportamento datoriale.

Infatti, l'aver incentrato il criterio selettivo e decisivo sulla base dell'esperienza maturata attraverso la presenza in servizio nel periodo precedente, ha oggettivamente svantaggiato l'unica persona che, suo malgrado, si è dovuta assentare o si è optato iure assentata per adempiere ai propri doveri correlati alla maternità. Peraltro, risulta che alla ricorrente non è stato consentito il lavoro da remoto in modalità smart working e ciò ha ovviamente acuito lo svantaggio della condizione di partenza.

In questa prospettiva, costituisce un palese riconoscimento di quanto testè chiarito l'affermazione contenuta in memoria secondo cui “la proroga è stata concessa a chi, per esperienza maturata sul campo e per continuità di servizio, risultava maggiormente qualificato per proseguire il lavoro senza necessità di ulteriore formazione o affiancamento. La ricorrente, avendo interrotto la propria attività per un periodo prolungato, non poteva offrire lo stesso livello di conoscenza operativa del progetto, determinando così una scelta imprenditoriale fondata esclusivamente su criteri di efficienza e razionalità organizzativa”.

Dunque, anche il criterio usato, di per sé neutro, in realtà ha avuto un impatto sulla platea di lavoratori interessati posti nelle medesime condizioni contrattuali di natura discriminante, creando uno svantaggio proprio a carico di colei che era portatrice del fattore di rischio protetto.

In sintesi, l'interessata ha provato il fattore di rischio, il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, deducendo una correlazione significativa fra questi elementi che rende plausibile la discriminazione; il datore di lavoro avrebbe dovuto dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria dell'atto, ma tale onere non è stato assolto (cfr. CGUE, sentenza 17 luglio 2008, causa C-303/06, *Per_14* sentenza 10 luglio 2008, causa C-54/07, *Per_1*, sentenza 16 luglio 2015, causa C- 83/14, *Chez*).

Resta fermo che il comportamento datoriale è sanzionabile in quanto oggettivamente discriminante, indipendentemente da una intenzionalità in tale direzione (cfr. Cass. n. 3361/2023), anche se il comportamento dei responsabili nelle interlocuzioni avvenute

per email con la ricorrente appare comunque contraddittorio e non trasparente, né corretto.

Per altro verso, va ribadito quanto chiarito dalla Suprema corte nella già citata sentenza n. 5476/2021, secondo cui “la questione sottoposta ai giudici di merito non è mai stata la sussistenza di un diritto soggettivo al rinnovo di un contratto a termine in essere tra le parti ma la sussistenza di una discriminazione per avere l' CP_3 convenuto concesso il rinnovo dei contratti a tutti i colleghi nelle medesime condizioni contrattuali della ricorrente e per non averlo riconosciuto a quest'ultima a causa del suo stato di gravidanza. Non vale, allora, invocare l'esercizio di un potere discrezionale circa l'opportunità di disporre il rinnovo di un contratto in scadenza e dedurre, come fa il controricorrente, che, nella specie, poteva solo sussistere una mera aspettativa di per sé non giuridicamente tutelata. Pur nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale è, infatti, possibile verificare se sia stato riservato un trattamento meno favorevole, a parità di situazioni, ad una lavoratrice in ragione del suo stato di gravidanza.

Dunque, la scelta datoriale oggetto di contestazione è da ritenersi *contra ius* e “la denuncia di un trattamento discriminatorio per la negata permanenza nel lavoro della ricorrente derivante dal congedo per maternità, a fronte del mantenimento in servizio di 'tutti' i suoi colleghi nelle medesime condizioni contrattuali” è fondata (Cass. ult. cit.).

6. *Conseguenze sanzionatorie*

La citata norma dell'art. 38 prevede che il giudice, “ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”.

La parte ricorrente ha in ricorso richiesto la rimozione degli effetti di tale comportamento illegittimo, con la conseguenziale declaratoria del diritto “alla proroga del contratto di lavoro nei medesimi termini con cui la stessa è stata asseverata nei confronti di tutti i colleghi che, al pari della medesima, parteciparono alla selezione ed hanno goduto della proroga, oltre che al risarcimento del danno che, in prima battuta, si quantifica nelle retribuzioni non godute dalla mancata proroga alla effettiva

ricostituzione del rapporto, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente per effetto della intervenuta discriminazione”.

La domanda è accoglibile solo nei limiti di seguito chiariti.

Infatti, la rimozione degli effetti del comportamento negativo posto in essere dalla resistente, consistente nella mancata proroga, a parità di condizioni del contratto, imporrebbe, ai fini di piena effettività del dictum di accertare il diritto della lavoratrice alla proroga del contratto alle medesime condizioni degli altri colleghi. Tuttavia, in primis non vi sono nella specie atti datoriali da potersi considerare invalidi e da potersi in ipotesi caducare, con un eventuale effetto riespansivo o restitutorio conseguente ipso iure al dictum del giudice.

Inoltre, essendo la relazione contrattuale ormai esaurita, preso atto dei poteri discrezionali contrattuali in materia e l'assenza di un diritto soggettivo assoluto pretensivo della ricorrente alla proroga, l'unica tutela attuabile è quella risarcitoria, essendo evidente che alcun ordine di conclusione di un contratto di proroga può essere imposto alla convenuta, che non è più la datrice di lavoro della ricorrente.

Può sul punto, mutatis mutandis, essere richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo n. 22029 del 12/07/2022) per cui il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva, è titolare di un diritto soggettivo alla partecipazione e all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere l'accesso e l'esecuzione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo in caso di esito positivo della selezione.

Quanto alla domanda di risarcimento da perdita di chance, in generale, circa questa tipologia di danno è prevalente la c.d. tesi ontologica secondo cui (cfr. ex plurimis, Cass. 2010/5119 e Cass. 2007/14820, ma anche Cass. S.U. 2009/1850, 2008/23846), il danno da perdita di chance non sarebbe configurabile come danno futuro, legato alla ragionevole probabilità di un evento, ma come danno concreto, attuale e certo, ricollegabile alla perdita di una prospettiva favorevole già presente nel patrimonio del

soggetto. Tale danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza.

Tale danno va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. Per l'esattezza, in tema di risarcibilità dei danni da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass., Sez. 3, n. 15274 del 4 luglio 2006).

Il dipendente è tenuto, allora, ad allegare l'esistenza di un danno da perdita di chance e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di probabilità.

Una volta fatto ciò, il giudice, che ritenga fornita tale prova, liquida il danno eventualmente in via equitativa.

Orbene, nel caso di specie, l'onere assertivo risulta assolto, posto la ricorrente ha dedotto circostanze o elementi indiziari che, anche solo in astratto, sono tali da poter ritenere in ipotesi lesa la chance sia pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità. In particolare, in assenza del comportamento discriminatorio, è da ritenere presumibilmente che la ricorrente – non risultando altri eventuali fattori ostativi - sarebbe stata destinataria di una proroga contrattuale sino alla scadenza della Convenzione, come prorogata sino al 30.4.2025.

Pertanto, il danno viene qui valutato equitativamente nella misura dell'80% delle retribuzioni che sarebbero maturate e che sono state perse dalla scadenza del contratto (31.12.2024) al 30.4.2025, commisurate alla retribuzione globale di fatto goduta durante il rapporto contrattuale.

Resta, infine, da valutare il danno non patrimoniale, da discriminazione e da violazione di norme unionali, cioè il cd. danno comunitario.

Al riguardo, si rendono indispensabili alcune precisazioni, sulla natura e sulla funzione dell'istituto risarcitorio *in subiecta materia*.

Dal punto di vista normativo, è bene premettere che il citato comma 5 dell'art. 28 del D.lsg.vo n. 150/2011 dispone che “con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole” ed al comma 6, prevede che “ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento”.

La specifica previsione del legislatore configura certamente uno strumento singolare, per funzione e struttura, rispetto al regime risarcitorio di diritto comune già presente nel sistema.

La natura *sui generis* della previsione, rispetto ai canoni generali valevoli *in subiecta materia*, è dimostrata sia dal richiamo alla facoltà per il giudice di provvedere alla risarcibilità anche del danno non patrimoniale, sia dal riferimento dell'incidenza, nella liquidazione, di fattori estranei tradizionalmente al danno subito come tale.

Evidentemente, in questo ambito ordinamentale, la funzione rafforzatrice delle tutele, in via punitiva, compulsiva o dissuasiva, si esplica e si giustifica (anche) quale misura di contrasto alla violazione del diritto eurounitario (Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5072). Il grado di giustiziabilità assicurato dal giudice esprime del resto l'inviolabilità o l'inderogabilità del diritto e costituisce un tassello fondamentale del rispetto del principio portante della *rule of law*.

Fondamentale, infatti, resta che, nella concreta tutela giudiziaria fornita, il rimedio alla discriminazione risponda ai requisiti stabiliti dal diritto unionale, dovendo cioè essere effettivo, proporzionale, dissuasivo (cfr. Cass., S.U., n. 5072 del 2016). Il principio di effettività è funzionale a garantire il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'UE nel singolo settore di intervento ed è sancito nell'art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, che

prevede: "gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione".

Dal punto di vista soggettivo, come chiarito dalla Cassazione (n. 20819/21) il principio di effettività rafforza i diritti riconosciuti dalle direttive ai singoli cittadini dell'Unione sul piano sostanziale e processuale (art. 47 CDFUE) e “pertanto ha anche la funzione di anticipare la soglia della tutela apprestata fino al punto in cui non vi siano vittime della discriminazione reali ma solo potenziali”.

Il risarcimento del danno, pertanto, si pone qui evidentemente con una funzione specifica, indirizzata a garantire che il sistema rimediale applicato risulti effettivo, proporzionale, dissuasivo. Nel caso di specie, si è dunque di fronte ad una norma speciale di riconoscimento di una deroga al principio generale di effettività o adeguatezza del danno, inteso strettamente come diminuzione patrimoniale, secondo la *Controparte_4*, corollario del principio di necessaria causalità di qualsiasi spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.

Invero, secondo l'interpretazione sistematica affermata a partire dalla nota sentenza delle Sezioni unite n. 5 luglio 2017, n. 16601 (ribadita da Cass. n. 33537/2022 ed altre), se è vero che in linea generale il nostro sistema di responsabilità civile e contrattuale resta fondato sulla funzione riparatoria del pregiudizio effettivamente subito, pur tuttavia, lo strumento risarcitorio può ben adempiere anche ad altre finalità, ponendosi quindi come misura polifunzionale.

In particolare, in caso di specifica, previsione legislativa, così come imposto dagli artt. 23 e 25 Cost, trovano riconoscimento i cd. "punitive damages" o altre figure caratterizzate da una funzione "ultracompensativa”.

Come chiarito nell'arresto delle Sezioni Unite (ma già SU n. 9100/2015) la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più «incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato *lato sensu* sanzionatorio al risarcimento. Le Sezioni Unite hanno tuttavia ribadito che questo connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una «qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25

Cost., comma 2, nonché dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.»

Questo giudice condivide a pieno la morfologia delineata dalla Suprema corte dell'istituto risarcitorio all'interno di una concezione polifunzionale della responsabilità, evidenziando come, a questi fini, rilevi sempre il canone di effettività, ma qui non riferito al ristoro risarcitorio (peraltro dovendo preferibilmente parlarsi di adeguatezza del medesimo), bensì alla tutela stessa.

Infatti, in casi quali il presente, oltre alla tutela di diritto comune, resta l'esigenza sia di assicurare adeguata sanzione, sia di garantire un effetto dissuasivo per il futuro o per altre posizioni analoghe, dunque tenendo conto della finalità punitiva, secondo la concezione retributiva (pena inflitta *quia peccatum est*), e secondo la concezione preventiva (*ne peccetur*).

La norma ha notevole potenzialità applicativa, peraltro, proprio in ipotesi, quali la presente, nelle quali risulta difficile allegare un documento certo e concreto subito, tenuto conto che il diritto rivendicato non ha natura pretensiva assoluta rispetto al bene della vita ambito.

Pertanto, il risarcimento del danno polifunzionale rinviene in questi casi utilità anche anticipatoria della soglia di protezione, nei termini indicati dall'organo nomofilattico (cfr. Corte Cost. 238/2014 e Cass. n. 21255/13), e non risulta in contrasto con il vigente ordinamento della responsabilità civile, al quale "non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile" (Cass. SS.UU. n. 16601 del 2017). La "curvatura deterrente/sanzionatoria" si fonda in ogni caso sulla norma esplicita indicata, quale necessaria "intermediazione legislativa".

Per completezza, data l'espressione testuale della norma, "con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale", si ritiene che il giudice abbia una propria facoltà ufficiosa di emettere questa pronuncia, in quanto immanente all'accertamento della violazione della disciplina antidiscriminatoria, trattandosi di rimedio volto a garantirne e consolidare

l'intrinseca effettività del *dictum* sanzionatorio. Ciò indipendentemente quindi dall'allegazione di concreti pregiudizi subiti o lamentati.

Pertanto, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 31071/2021) anche a non voler ritenere inclusa tale voce nella domanda risarcitoria comunque avanzata, non si ritiene in ogni caso necessaria una esplicita richiesta, né prova di questa voce di danno, pur dandosi atto che nel ricorso tale richiesta è stata formulata.

Il Giudice, in applicazione di tali principi e criteri, ritiene quindi di dover riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale subito per il titolo indicato, per effetto di quanto sopra, da contenersi entro limiti di adeguatezza e ragionevolezza, per l'esigenza comunque di preservare il rispetto di istanze di equilibrio e bilanciamento (Corte costituzionale sentenze nn. 148 del 1999, 199 del 2005, n. 420 del 1991, n. 303 del 2011, n. 235 del 2014).

A tale fine, si reputa equo liquidare a titolo risarcitorio una somma complessiva pari ad € 8.000,00, che tiene conto in via solo orientativa delle tabelle stipendiali previste, della gravità della discriminazione e del comportamento delle parti.

11. Il regime delle spese di lite

Le spese di lite sono poste integralmente a carico convenuto secondo il criterio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..

Nella liquidazione delle spese del giudizio nell'importo di cui al dispositivo si è tenuto conto della tabella allegata al Dm n. 147/2022, relativa ai procedimenti in materia di lavoro, del valore indeterminabile della controversia, delle questioni trattate e si sono considerate le fasi processuali correlate all'attività defensionale svolta.

PQM

1. accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dalla parte convenuta consistita nella mancata proroga del contratto di lavoro a termine della sola ricorrente;
2. condanna, per conseguenza, la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale causato alla ricorrente, liquidato in un importo corrispondente

all'80% delle retribuzioni che sarebbero spettate dal 1.1.2025 al 30.4.2025 e al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in complessivi € 8.000,00;

3. condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 5.959,99, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.

Si comunichi con urgenza

Roma, 20.3.2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Casola